

1502457-37.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... por insuficiência de provas quanto ao tráfico.

Diante disso, ou seja, da absolvição do corréu e por não estar demonstrada a participação do adolescente no tráfico, afastado o aumento do art. 40, inc. VI, quanto ao réu Rodney.

Assim, impõe-se a condenação do acusado Rodney pelo tráfico, posto que a materialidade está provada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502457-37.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502457-37.2021.8.26.0537

2021/001807

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODNEY GUSTAVO SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RODNEY GUSTAVO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e FELLIPE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, e no art. 180, "caput", do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 09:40 horas, na Passagem São Marcos Evangelista, n.º 67, Bairro Campanário, previamente ajustados e com divisão de tarefas com o adolescente Lucas V.A.N, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega e consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda da denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, FELLIPE FERREIRA DA SILVA, adquiriu e recebeu, em provento próprio, o aparelho de telefone celular marca/modelo Samsung Galaxy A20, pertencente a Décio Ferreira Martinez, sabendo tratar-se de produto de crime.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas na audiência de custódia (fls. 76/78).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 177/178), sendo recebida a denúncia em 24.01.22 (fls. 158). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. Os réus foram interrogados no final, porquanto foi adotado o rito ordinário, tendo em vista o princípio da ampla defesa (fls. 158).

A Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência parcial da ação, com a condenação do réu Rodney pelo tráfico, afastando-se o art. 40, com aumento da pena pela quantidade de drogas e por ter passagem por ato infracional, que sejam consideradas as atenuantes da confissão e pela menoridade, afastada a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime fechado; quanto ao réu Fellipe a condenação apenas pela receptação, com aumento da pena por ter ato infracional, regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

O Dr. Defensor requereu a absolvição por insuficiência probatória ou em caso de condenação, que seja afastado o art. 40, inc. IV da Lei de Drogas, a confissão e menoridade do réu Rodney, detração, regime aberto e substituição por restritiva e quanto ao réu Fellipe também por atipicidade da receptação por ausência de dolo, regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, os réus permaneceram calados (fls. 09 - réu Rodney e fls. 16 - réu Fellipe).

O acusado Rodney, em juízo, confessou a prática do crime, alegando que aceitou guardar as drogas na sua casa e receberia R200,00 por semana. Afirmou que saiu junto com o corréu e o menor. Informou que pegou a droga na viela e foi abordado por policiais. Indicou o local onde tinha mais drogas. O réu Felipe e o menor estavam dormindo nesse local, que era sua casa e estava em construção. Trabalhava como pizzaiolo, sua mulher estava grávida, queria fazer o enxoval, estava passando por dificuldades e aceitou trabalhar no tráfico. Quando menor ficou internado por um roubo de carro. Nada tem contra os policiais. Está arrependido e pede uma oportunidade. Tem 19 anos.

O réu Fellipe, em juízo, narrou que saíram ele, o corréu e menor. Informou que dormiu na casa de Rodney, com quem trabalhou anteriormente. O celular comprou no Facebook, mas como era modelo antigo, não desconfiou. Não recebeu nota fiscal, nem a caixa, porque a vendedora falou que perdeu durante a mudança de casa. Teve um ato infracional pelo art. 157. Não desconfiou que pudesse ter drogas na casa de Rodney, porque já trabalhou com ele e o mesmo não é usuário.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/06), disseram que o policial Lucas recebeu informe anônimo relatando que homens estavam armazenando drogas no local dos fatos, com a finalidade de abastecer "biqueiras" existentes no município. Narraram que se dirigiram até o local dos fatos em uma viatura descaracterizada e realizaram uma campanha. Relataram que o local se tratava uma construção aparentemente abandonada, cuja entrada não tinha porta, onde visualizaram o réu Rodney, portando uma bolsa de cor marrom, e resolveram abordá-lo. Afirmaram que no interior da bolsa de cor marrom, que o réu Rodney trazia consigo, localizaram 24 porções de maconha, 50 pedras de "crack" e 50 porções de cocaína. Falaram que o réu Rodney informou que havia mais drogas e pessoas no interior da construção.

Declararam que ao adentrarem no local se depararam com o réu Fellipe e o adolescente Lucas em um cômodo e localizaram dentro de um guarda-roupa uma sacola de cor preta, cujo interior continha 300 porções de maconha, 250 pedras de "crack" e 200 invólucros de "cocaína". Informaram que no local havia uma motocicleta marca Honda CG 160, de cor vermelha e sem emplacamento, que foi apreendida e levada ao distrito policial, onde foram feitas pesquisas pelo número do chassi e se constatou que referido motociciclo não estava cadastrado na base de dados do DETRAN/DENATRAN, pelo que não puderam identificar o proprietário ou possuidor do bem. Relataram que foi constatado em pesquisas que o réu Fellipe era procurado pela Justiça, em razão de mandado de prisão emitido pela 1.ª Vara Criminal desta comarca aos 02.10.20, referente ao processo n.º 1501008-42.2020.8.26.0161. Afirmaram que

apreenderam na posse do acusado Fellipe um aparelho de telefone celular da marca Samsung, que em pesquisa pelo número de IMEI constataram se tratar de produto de furto, ocorrido em 11.10.19 e registrado no B.O n.º 1300670/2019 na delegacia eletrônica (fls. 61/62).

Lucas (policial), em juízo, informou que receberam uma denúncia que no local havia tráfico e armazenavam as drogas para distribuir para as "biqueiras". Foram até o local e viram o réu Rodney com uma bolsinha na entrada desse imóvel, que parecia uma casa abandonada. Na bolsinha havia drogas, divididas em porções. O réu Rodney disse que havia mais pessoas e drogas no interior da residência. Entraram no local, localizaram mais drogas divididas em porções) dentro do guarda-roupa e um celular com o réu Felipe que constava como produto de crime. Disse que o réu Rodney confessou que guardava a droga no local e os outros estavam no local apenas dormindo. Felipe e o menor falaram que resolveram dormir no local. Acharam drogas no guarda-roupa após procurarem. Informou que o réu Felipe e o menor estavam sentados na cama, mas não estavam dormindo. Havia uma cama no imóvel e guarda-roupa. Não conhecia os réus. O réu Fellipe constava como procurado.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Denny. Informou que o réu Rodney confessou e disse que tinha mais drogas na casa. O corréu Felipe e menor estavam dormindo e negaram o tráfico. Informou que o réu Rodney disse que as drogas eram dele e que os demais estavam apenas dormindo. Disse que o réu Felipe e o menor disseram que estavam no local apenas dormindo, porém não souberam dizer de quem era o imóvel. O guarda-roupa na qual foram achadas as drogas estava no mesmo cômodo onde o réu Felipe e o menor dormiam. Não conhecia os réus.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 33 - 324 porções de maconha, 250 invólucros de cocaína e 300 pedras de "crack"), aliados à confissão judicial do réu Rodney, falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida individualmente em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu Rodney e na sua casa (fls. 33 - 324 porções de maconha, 250 invólucros de cocaína e 300 pedras de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Quanto ao réu Fellipe em juízo negou a prática do crime, foi inocentado pelo corréu Rodney, as drogas não foram apreendidas em seu poder, já que estavam no interior do guarda-roupa do cômodo onde dormia, sequer houve confissão informal, pelo que é caso de absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico.

Diante disso, ou seja, da absolvição do corréu e por não estar demonstrada a participação do adolescente no tráfico, afasto o aumento do art. 40, inc. VI, quanto ao réu Rodney.

Assim, impõe-se a condenação do acusado Rodney pelo tráfico, posto que a

materialidade está provada pelos laudos de constatação (fls. 43/46 e 49/52) e laudos definitivos (fls. 100/102 e 103/105).

O telefone celular marca/modelo Samsung Galaxy A20 é produto de furto, conforme B.O. de fls. 61/62, e foi apreendido em poder do réu Fellipe.

"PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

Considerando que o acusado Felipe alegou que comprou o celular pelo Facebook, sem nota fiscal e sem caixa, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP , isso demonstra que sabia da procedência ilícita do bem, pelo que inviável a absolvição.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a "res" apreendida em poder do acusado, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha lícitamente, o que não fez, pelo que é caso de condenação.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados, que segundo consta dos autos são primários (fls. 179/182 - réu Felipe; fls. 183/185 - réu Rodney). O réu Felipe possui um processo em andamento (fls. 210 - proc. 3050-07.2021, desmembrado do proc. 1501008-42.2020), que não pode ser considerado para quaisquer fins, por ofensa ao princípio do estado de inocência.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 334). Inobstante os réus tenham respondido por atos infracionais (fls. 71 - réu Rodney; 212/221 - réu Felipe), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seus desfavores, já que conforme F.As de fls. 179/182 e 183/185, são primários e possuem antecedentes criminais (STJ, 5.ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o réu Rodney pelo tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica dos acusados. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão judicial, porque já foram aplicadas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (324 porções de maconha, 250 invólucros de cocaína e 300 pedras de "crack") já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei à redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020 ), porque o réu Rodney é primário, não ostenta antecedentes criminais é menor de 21 anos, pelo que

as circunstâncias judiciais são favoráveis e o caráter hediondo do tráfico privilegiado foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ. Quanto ao crime de receptação praticado pelo réu Fellipe, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Deixo de diminuir a pena pela menoridade do acusado, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, por ser primário, e o dia-multa à razão mínima em face de sua situação econômica. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RODNEY GUSTAVO SANTOS à pena de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e FELLIPE FERREIRA DA SILVA, à pena de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, por se achar incurso no art. 180, "caput", do Código Penal e o ABSOLVO da imputação de se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020 em relação ao tráfico, sendo as penas privativas de liberdade superiores a um ano as quanto ao réu Rodney substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta e em relação ao réu Fellipe cuja pena é igual a 1 anos por prestação de serviços à comunidade. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica dos acusados. As penas restritivas de direitos terão a mesma duração das penas privativas de liberdade substituídas (art. 55 do Código Penal). Os acusados poderão recorrer em liberdade, uma vez que são primários e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados, observando-se que o acusado Fellipe também está preso em razão do mandado de prisão preventiva emitido no processo n.º 0003050-07.2021.8.26.0161 da 1.ª Vara Criminal local (fls. 210). Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03). Quanto às bolsas apreendidas (fls. 32) e já periciadas (fls. 44 e 50), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas. Não há provas de que motocicleta marca/modelo Honda CG 160 START, cor vermelho, ano/modelo 2021/2022, sem emplacamento, apreendida (fls. 32) era utilizada ou proveito do tráfico, pelo que oficie-se, desde já, informando que devem ser tomadas as providências necessárias para eventual liberação ao seu legítimo proprietário ou, não havendo interesse por parte deste, que seja levado a leilão público, nos termos da Lei Federal 6575/78 e art. 328 do C.T.B. Em relação ao smartphone marca/modelo Samsung Galaxy A20, tendo em vista ser produto de furto (fls. 61/62), deverá ser providenciada sua restituição ao proprietário, caso não tenha sido feito. Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 81) e providencie-se o cálculo das multas, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Diadema, 12 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA